

1500201-47.2021.8.26.0691

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GILVANA MASTRANDÉA DE SOUZA

Comarca: Buri

Foro: Foro de Buri

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... sentido:

"Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade. Violação de domicílio. Diligência policial efetuada para averiguação de denuncia anônima da prática de tráfico. Apreensão de porções de maconha e petrechos apropriados para o fracionamento de drogas. Crime permanente. Rejeitada. No mérito, pretensão de absolvição ao argumento de insuficiência probatória ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Buri

Foro de Buri

Vara Única

Rua Carlos Alberto Pereira Jr, 549, Buri - SP - cep 18290-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500201-47.2021.8.26.0691 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500201-47.2021.8.26.0691

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR DE SOUSA

Juíza de Direito: Dra. GILVANA MASTRANDÉA DE SOUZA

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de JOÃO VITOR DE SOUSA, já qualificado nos autos em epígrafe, que apura a suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 e 307 c.c art. 61, II, "j", tudo na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal.

Segundo consta na denúncia de fls. 114/117, no dia 21 de junho de 2021, por volta da 1h20, na Rua Progresso, 1, Vila Sene, nesta cidade e Comarca de Buri, o réu, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, guardava, transportava e mantinha em depósito, drogas consistentes em 06 (seis) porções de cocaína, sob a forma de crack, pesando 175,15g de massa líquida, e 86 (oitenta e seis) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 176,35g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar .

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de local e data acima descritas, o réu, em ocasião de calamidade pública, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio.

Sustentou o Ministério Público, "Segundo o apurado, policiais militares foram informados de que no local acima descrito estaria ocorrendo a venda de drogas. Dirigiram-se para lá e, em patrulhamento, depararam-se com o denunciado, que, ao dar de frente com eles, de imediato retornou. Diante da atitude suspeita do denunciado, ele recebeu voz de abordagem, da qual tentou fugir sem sucesso. Em revista pessoal, encontraram em um dos bolsos da sua calça R\$57,00 (cinquenta e sete reais) em dinheiro; e no outro, um aparelho celular. No bolso da sua blusa, ainda, encontraram 04 (quatro) pedras de crack. Destaque-se que, durante a entrevista dos policiais, o denunciado se identificou com nome falso e número do documento de identidade incorreto, além de não declinar seu endereço, com a finalidade de furtar-se da ação policial e evitar a apreensão de outras drogas. Somente com a chegada de policiais locais foi aclarada a qualificação e identificação do acusado. Ato contínuo, os policiais dirigiram-se até a residência do denunciado - entraram com a permissão da genitora -, onde encontraram, em seu quarto, dentro do guarda-roupas, mais 86 (oitenta e seis) porções de maconha e 02 (duas) porções de crack. A quantidade e diversidade das drogas, modo de acondicionamento, o dinheiro apreendido e demais circunstâncias da prisão, demonstram que os entorpecentes se destinavam mesmo a entrega de terceiros". Preso em flagrante no dia dos fatos (fls. 01-02 e 03), foi convertida em prisão preventiva no mesmo dia (fls. 53-62).

O Ministério Público ofereceu denúncia em 28.07.2021 (fls. 114-117) e no dia 29.07.2021 foi determinada a notificação do denunciado para os fins do art. 55 da Lei 11.343/06 (fls. 118-119).

Notificado (fl. 134), o denunciado apresentou defesa preliminar (fls. 136-137).

A denúncia foi recebida no dia 30.08.2021. Na mesma oportunidade foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 140-141).

Durante a instrução, foi produzida prova testemunhal e o réu foi interrogado.

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal a Defesa postulou diligências, as quais foram cumpridas (fls. 204/205 e 211).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia (fls. 215/221), ao passo que em sua Defesa do réu propugnou por sua absolvição (fls. 226/232).

É o relatório, no essencial. Passo a fundamentar e a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, rejeito a preliminar levantada pela Defesa de que a localização das drogas na residência do réu foi ilegal. Isto porque os policiais militares foram firmes ao indicarem, nas duas fases da persecução penal, que a genitora do réu autorizou o ingresso na residência, o que retira eventual ilegalidade. O consentimento para ingresso na residência veio, ainda, confirmada pelo vídeo de fl. 211, sem qualquer indício de que a genitora estivesse sendo coagida ou ameaçada pelos milicianos.

De toda forma, ainda que assim não fosse, verifica-se que o acusado estava em situação de flagrância, tendo sido localizado na posse de drogas pouco tempo antes, o que autorizaria o ingresso em sua residência (artigo 5º, XI, da CF), visto que o crime de tráfico na modalidade "manter em depósito" é de consumação permanente.

Tratando-se, portanto, de crime permanente, e estando em evidente estado flagrancial, os policiais estariam autorizados a ingressar na residência do acusado, sem a necessidade de mandado judicial e sem qualquer ilegalidade.

Neste sentido:

"Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade. Violação de domicílio. Diligência policial efetuada para averiguação de denúncia anônima da prática de tráfico. Apreensão de porções de maconha e petrechos apropriados para o fracionamento de drogas. Crime permanente. Rejeitada. No mérito, pretensão de absolvição ao argumento de insuficiência probatória e aplicação do princípio da presunção da inocência e do in dubio pro reo. Pedidos subsidiários de fixação da pena base em 1/8 acima do mínimo legal e o abrandamento do regime prisional. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses secundárias afastadas. Penas e regime adequados e fundamentandos. Recurso improvido". (TJSP; Apelação

Criminal 1501891-93.2019.8.26.0073; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020) O tipo objetivo do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

Ainda, quanto ao pedido formulado pela Defesa da necessidade de oitiva da genitora, reitero os termos da decisão que indeferiu sua oitiva em audiência: "INDEFIRO o pedido de oitiva da testemunha arrolada às fls. 196, considerando que: (i) a testemunha foi arrolada intempestivamente, muito depois do prazo previsto em lei (que prevê que as testemunhas devem ser arroladas na defesa prévia), ou seja, depois da primeira audiência de instrução; (ii) não se trata de testemunha nova, que surgiu durante a instrução processual, existindo referência de que a genitora autorizou a entrada dos policiais desde a fase investigativa (fls. 10/13); (iii) se trata da genitora do réu, logo, seria ouvida como informante, sem compromisso de dizer a verdade, não mostrando que seu depoimento seja imprescindível para resolução do feito." (fls. 197/198).

Superadas estas premissas, passa-se à análise do mérito propriamente dito.

Com efeito, o auto de exibição e apreensão de fls. 13-14 demonstra que foram apreendidas na posse do réu 04 (quatro) pedras de "crack", pesando 191,07g (cento e noventa e uma gramas e sete centigramas) de massa líquida; 86 (oitenta e seis) porções de "maconha", pesando 196,69g (cento e noventa e seis gramas e sessenta e nove centigramas) de massa líquida; e 02 (duas) porções de "crack", pesando 5,65g (cinco gramas e sessenta e cinco centigramas) de massa líquida, 01 (um) telefone celular, marca samsung e R\$ 57,00 em dinheiro.

Anote-se que, conforme conclusões dos laudos periciais preliminares de fls 19-19 e 20-23 e laudos de Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo de fls. 100-103 e 104-107, constatou tratar-se de substâncias entorpecentes as matérias apreendidas (art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/06), quais sejam, cocaína na forma de "crack" e "maconha".

Referidas provas demonstram, além de qualquer dúvida razoável, a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado JOÃO VITOR DE SOUSA foi o autor dos crimes descritos na denúncia, conforme será devidamente demonstrado a seguir.

Com efeito, as provas colhidas durante a instrução processual e elementos informativos angariados na fase inquisitorial são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

A testemunha MARCELO HENRIQUE PINHEIRO, policial militar, declarou perante a autoridade policial que (fl. 04): "com relação aos fatos em questão tem a esclarece que nesta data estava de serviço com CB Rafael e receberam denúncia anônima informando que na Rua Progresso com cruzamento com a Rua Alfredo Francisco de Oliveira, era local de venda de entorpecentes. Após denúncia foi feito patrulhamento mas nada foi localizado, momento em que o indiciado virou a esquina e deu de frente com a viatura, de pronto retornou e quando recebeu voz de abordagem começou a acorrer, mas foi possível conte-lo a poucos metros. Após revista pessoal foi localizado com o mesmo a quantia de R\$57,00 (cinquenta e sete reais) no bolso lateral direito da calça e no bolso lateral esquerdo da calça um aparelho celular da marca Sansung. No bolso da blusa foi localizado quatro pedras de substância aparentando ser crack. Durante a entrevista o indiciado mentiu o nome por várias vezes, informou numero de identidade errado e não quis passar o endereço, motivo pelo qual solicitaram apoio dos policiais de Buri e estes reconheceram o indiciado e informaram que seu nome era João Vitor de Souza e que residia próximo. Se deslocaram até a residência do indiciado e lá com autorização de sua genitora adentraram o quarto do indiciado e em seu guarda roupas foi localizado mais 86 (oitenta e seis) porções de maconha e duas porções de crack. Após ser dado voz de prisão ao indiciado, este resistiu sendo necessário uso de força moderada e

algemas. Informa ainda que a autorização para entrada dos policiais que foi dada pela genitora foi gravada. Informa ainda que o autor saiu de saída temporária da penitenciária de Guareí, onde estava preso por tráfico de entorpecentes e iria retornar no dia 21.06.2021" (sic).

Em juízo narrou que: "na data dos fatos comandava pelotão de força tática e durante patrulhamento de Buri, foi realizada a abordagem do João Vítor e ele apresentou nervosismo quando observou a viatura; que ele tentou mudar de caminho quando observou a viatura e isto levantou suspeita; durante a abordagem, junto com ele, foi encontrada certa quantidade de entorpecentes; o réu falava que ia encontrar uma namorada e negou a fornecer os dados; foi solicitado apoio da autoridade, e então foram até a residência do réu, conversaram com a genitora e ela autorizou a entrada na residência; foi ela que avisou que ele estava de saidinha e retornaria no dia posterior à data dos fatos; ela guiou para dentro da residência e mostrou onde ficavam os pertences do réu, e ali existiam drogas picadas para o comércio; no momento da abordagem não tinha dinheiro, apenas pedras de crack; que o réu negou a propriedade das drogas, afirmando que poderia ser do irmão, mas a mãe negou falando que onde as drogas foram localizadas estavam os pertences apenas do João Vítor; não lembra dos policiais de Buri que estavam nesta ocorrência; que o réu não apresentou documento; primeiro ele se fingiu de surdo e depois que ele começou a conversar direito; o réu não falou o nome direito completo, nem a filiação, tampouco a matrícula; não lembra os nomes que o réu falava que tinha; na época foram feitas várias pesquisas, com vários nomes e várias datas de nascimento, mas nenhum batia". No mesmo sentido foram as declarações do seu colega de farda RAFAEL FAGUNDES DE ARAUJO ROCHA (fl. 05) e em juízo asseverou que: "que receberam denúncia via copom, que no local onde o réu foi abordado, estava ocorrendo tráfico de drogas; que por causa da denúncia, resolveram averiguar; que começaram o patrulhamento, e que no primeiro momento não constatarem nada, todavia o acusado viu a viatura e tentou correr; que abordaram o acusado, e em revista pessoal encontraram no bolso de sua calça certa quantidade de dinheiro, um celular e quatro porções de crack; indagado sobre seu nome, endereço e antecedentes criminais, o acusado entrou em contradição, então os policiais entraram em contato com a polícia de Buri, e informaram que o acusado é conhecido no meio policial por tráfico de drogas, e que ele estava preso, através de consulta viram que o acusado estava de saída temporária; que entraram em contato com a mãe do acusado, e pediram permissão para entrar na casa; que no quarto do acusado encontraram 86 porções de maconha e 02 de crack; que solicitaram os policiais de Buri após a abordagem do réu; que no momento da revista na casa do acusado, os policiais de Buri acompanharam o declarante e seu colega de farda; que na data da abordagem o acusado estava usando uma calça preta e uma blusa escura; que no momento da abordagem o acusado deu outros nomes, bem como não quis dizer onde morava; que o acusado não estava portando documento; que foram até a residência do réu para ver os documentos e para saberem se tinha mais drogas; que as drogas encontradas na casa do réu estavam em uma gaveta de um guarda roupa; que o policial de Buri que os acompanhou para revista na residência do réu se chama Fabio Laureano".

Em seu interrogatório perante a Autoridade Policial o acusado JOÃO VITOR DE SOUSA, por sua vez, negou a traficância e a posse/propriedade das drogas apreendidas. A propósito (fls. 06-07): "que estava indo na casa de sua mulher quando foi abordado por policiais militares que perguntaram se tinha alguma coisa e respondeu que não. Então foram na casa do interrogando, entraram e quando saíram falaram que tinham encontrado vinte e cinco peteca de maconha. A droga não é do interrogando e nem sabe o que está fazendo aqui. Não reconhece o crack. A mãe do interrogando é testemunha que não foi encontrado nenhum cartucho azul. Já foi preso por tráfico de entorpecentes" (sic).

Interrogado em juízo, o réu narrou que: "recebeu benefício de "saidinha" e estava na casa de sua genitora, e recebeu R\$ 150,00 do seu tio e foi para uma mercearia comprar produtos de higiene. Estava conversando pelo celular da genitora com uma moça e marcou um encontro 20h30, e saiu da residência neste horário. Foi até a casa da menina, entrou na casa dela, mas não ficou lá, optou por voltar para a casa. Estava carregando um salvo-conduto, com identificação da unidade prisional com

indicação que estava com "saída temporária". Estava caminhando na Via Progresso, e chegaram duas viaturas, mas não tinha o que temer a polícia porque não estava com entorpecente. A Força Tática passou pelo depoente e tinha outra viatura passando atrás deles, o Fábio e Negrini, mesmo processo que está preso de 2018. Eles abordaram o interrogado, a Força Tática parou na frente. O Fábio questionou se tinha saído. Policiais exibiram a foto de algumas pessoas e pediram para que o réu mostrasse onde eles moravam. Respondeu que não sabia, então os policiais deram um chute contra o interrogado, cuspiu sangue. Isto constou no laudo do IML. Os policiais militares começaram a falar para a Força Tática que o interrogado prejudizou eles em 2016. Não teria como comprar tudo isto de droga, que vale mais de 10 mil reais. Não viu a droga. Não tem bolso na blusa, e sim na calça. Estava com um termo de responsabilidade no centro. Não sabe o número do RG de "cabeça". Afirmou que ficou na esquina em uma viatura com os policiais Fábio e Paulo, e eles se encaminharam até a casa. Viu os policiais saindo com seu RG, mas com drogas não.

I.1. Do suposto crime de tráfico de drogas:

Dos depoimentos acima transcritos, se extrai, além de qualquer dúvida razoável, que a droga apreendida era de propriedade do réu e destinada ao tráfico.

Com efeito, os policiais militares confirmaram que as drogas estavam na posse do réu, assim como no interior da sua residência, cuja entrada foi autorizada pela mão do acusado.

Some-se a isso o fato de que na posse do réu foi apreendida expressiva quantidade de drogas de natureza variada – maconha e crack (fotos às fls. 19 e 23), sobretudo se comparada com a traficância ordinária da região, incompatível com a mera alegação de uso, valendo ressaltar que a versão do réu sequer é verossímil, de que os policiais estão mentindo para prejudicá-lo falsamente. A alegação de perseguição, aliás, está isolada nos autos e não veio minimamente demonstrada. Por outro lado, verifica-se que o réu já tem condenação pela prática de crime de tráfico de drogas (autos n. 0000234-19.2018.8.26.0691, fl. 186), e quando era menor também foi responsabilizado pela prática do mesmo delito tendo sido internado na Fundação Casa (autos n. 0000190-81.2016.8.26.0691), tudo a evidenciar que faz da mercancia de drogas seu meio de vida, tendo aproveitado os poucos dias de saída temporária (e descumprindo dever de permanecer à noite em sua casa) para cometer novamente o delito.

Neste aspecto, aliás, não é crível que os policiais militares, que possuem diversas diligências e patrulhamento ostensivo para cumprir, tenham aguardado a saída do réu da prisão para então forjar tamanha quantidade de droga dentro de sua residência. No que tange ao depoimento de policiais militares, ressalta-se não existir dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, têm os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho. Ademais, nos casos de tráfico de drogas, onde o testemunho civil é quase sempre impossível, deve ser conferido às declarações do policial o merecido valor em confronto com os demais elementos de convicção trazidos aos autos.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal”. (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta

Turma).

Vale ressaltar, outrossim, que nada de concreto foi trazido pela defesa que afastasse a credibilidade dos depoimentos dos Policiais Militares, servidores públicos que sequer conheciam os réus.

Ademais, as circunstâncias do encontro das substâncias entorpecentes, além do que já se expôs, geram a convicção da posse voltada para o comércio e não a finalidade para o uso próprio. Nessa mesma ordem de ideias, conforme trecho do v. acórdão proferido na Apelação nº 0000926-20.2016.8.26.0616, "Por outro lado, o crime de tráfico de entorpecentes é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ele representa para a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade de venda". (TJSP; Apelação 0000926-20.2016.8.26.0616; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro: 03/08/2018).

Ainda, em consonância com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a caracterização do crime de tráfico e drogas prescinde que o réu seja surpreendido no momento da realização da mercancia da droga, especialmente porque o tipo penal é misto alternativo e a prática de qualquer conduta do núcleo do tipo caracteriza do delito. A propósito: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP - AC 20.239 - Rei. Geraldo Gomes-RT 584/347); "TÓXICOS - Tráfico - Prova de algum ato de comércio - Desnecessidade - Trazer consigo ou manter a droga em depósito para venda, ainda que futura - Suficiência, na medida em que a consumação do delito não exige qualquer resultado Recurso parcialmente provido para reduzir as penas impostas e estabelecer o regime inicial fechado." (Apelação Criminal n. 1.141.860-3/6 São Paulo 5ª Câmara Criminal Relator: Pinheiro Franco 14.02.08 V.U. Voto n. 10.277).

Diante do exposto, resta afastada a tese de absolvição do réu.

II.2. Do suposto crime de falsa identidade (CP, art. 307):

De igual modo, o crime de falsa identidade, previsto no artigo 307, do Código Penal, restou configurado.

Com efeito, o réu JOÃO VITOR DE SOUSA se identificou perante os policiais militares com outro nome, informou número de identidade errado e não quis passar o endereço, motivo pelo qual, os policiais militares solicitaram apoio dos policiais de Buri e estes reconheceram o indiciado e informaram que seu nome era João Vitor de Souza e onde ele residia.

Nesse particular, emerge inviável o reconhecimento da tese de atipicidade de conduta, em razão da alegada ausência de dolo ou porque sua conduta teria consistido mero exercício de autodefesa, pois quem é acusado da prática de um crime tem o direito de ficar em silêncio ou de faltar com a verdade a respeito do fato que lhe é imputado, mas nunca o de falsear a própria identidade, ainda que para ocultar seu envolvimento em outro delito.

A questão encontra-se pacificada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula nº 522: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".

Esse também é o entendimento reafirmado na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede do julgamento da Repercussão Geral em Recurso Extraordinário. Confira-se: "EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar

maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes.” (Tribunal Pleno, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 640.139/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ 22.09.2011).

Não é outro o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO e FALSA IDENTIDADE – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Palavra e reconhecimento da vítima corroborado pelo conjunto probatório – Validade – Depoimento do policial firme e harmônico, que se revestem de fé pública – Ausência de intuito de prejudicar o acusado – Possibilidade de aplicação da causa de aumento pelo repouso noturno tratando-se de delito na forma qualificada – Precedentes – Desclassificação para a modalidade tentada – Descabimento – Direito à autodefesa – Não ocorrência – Inteligência à Súmula 522 do STJ – Ainda que haja a intenção de se autodefender, a conduta de fornecer nome falso atenta contra a fé pública e induz a erros as autoridades na persecução penal, permanecendo típica a conduta – Pena e regime bem fixados que não comportam alteração – Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação Criminal 0006501-03.2019.8.26.0099; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista – 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020); “Tráfico de drogas – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Provas suficientes à condenação por tráfico – Inviabilidade da desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal – A conduta do acusado de se atribuir falsa identidade perante os policiais civis é típica – Precedente do STF – Básicas tornadas ao piso – Inexistem maus antecedentes, uma vez que estes só se configuram quando há um fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime analisado – A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, por si só, neste caso, não exige maior censura – O réu, por ser reincidente, não tem direito ao redutor do tráfico privilegiado – Regimes fechado, para a pena de reclusão, e semiaberto, para a detenção, mantidos, diante da quantidade de pena aplicada e da reincidência”. (TJSP; Apelação Criminal 1501728-36.2019.8.26.0616; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes – 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020).

Assim, devidamente comprovada a prática do crime tipificado no art. 307 do Código Penal pelo réu JOÃO VITOR DE SOUSA.

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o réu JOÃO VITOR DE SOUSA, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 33, caput, 11.343/06 e art. 307, tudo na forma do art. 69, caput, ambos do Código Penal.

Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto à presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, está analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o réu sequer suscitou a existência de dirimentes.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, porquanto o réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu JOÃO VITOR DE SOUSA, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, 11.343/06 e

art. 307, tudo na forma do art. 69, caput, ambos do Código Penal.

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, verifica-se que a culpabilidade do réu foi exacerbada, porque praticou o crime enquanto estava sendo beneficiado pela saída temporária, e descumprindo uma de suas condições (proibição de se ausentar de sua residência entre as 19h e 06h, conforme documento de fl. 37), a evidenciar total descrédito à justiça, além disto, o "crack" é substância entorpecente altamente viciante e destrutiva (natureza da droga), e a quantidade de droga foi expressiva - 04 (quatro) pedras de "crack", pesando 191,07g (cento e noventa e uma gramas e sete centigramas) de massa líquida; 86 (oitenta e seis) porções de "maconha", pesando 196,69g (cento e noventa e seis gramas e sessenta e nove centigramas) de massa líquida; e 02 (duas) porções de "crack", pesando 5,65g (cinco gramas e sessenta e cinco centigramas) de massa líquida - conforme se observa pelas fotos de fls. 19 e 23 -, tudo a demonstrar que a pena deve ser aumentada nesta fase. Assim, diante da presença de circunstâncias negativas na prática do crime de tráfico de drogas, majoro a pena nesta fase em 1/5 (um quinto), resultando em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos dias-multa) para o crime do artigo 33, da Lei de Drogas.

Em relação ao crime de falsa identidade, as circunstâncias são normais à espécie, motivo pelo qual fixo no mínimo legal, em 03 meses de detenção para o crime do art. 307 do Código Penal.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Ressalta-se, outrossim, a não aplicação da agravante relacionada pelo Ministério Público prevista no art. 61, II, j, do Código Penal, dado que tal circunstância (calamidade pública) não guarda nexos causal com o caso, sendo que o réu não se aproveitou da situação de pandemia causada pelo COVID-19 para o cometimento do delito. Adota-se, pois, interpretação restritiva acerca da aplicação dessa agravante, sob pena de aplicá-la a todo e qualquer delito cometido em território nacional a partir de 16.03.2020. Em suma, não há que se falar em reconhecimento da agravante. Nesse sentido: "AP 1511467-48.2020.8.26.0050 - Xisto Rangel 10/03/2021 TJSP/13ªC; AP 1500832-75.2020.8.26.0545 - Mário Devienne Ferraz 09/03/2021 TJSP/1ªC; HC 629.867-SP - Sebastião Reis Júnior 1º/02/2021 STJ/Monocrática; AP 1501501-76.2020.8.26.0530 Leme Garcia 15/03/2021 TJSP/16ªC; AP 1511385-65.2020.8.26.0228 Reinaldo Cintra 11/03/2021 TJSP/7ªC; AP 1501114-35.2020.8.26.0571- Camargo Aranha Filho 18/12/2020 TJSP/16ªC".

Por outro lado, em relação ao crime de tráfico de drogas, presente a agravante da reincidência específica (autos nº 0000234-19.2018.8.26.0691 - data do fato em 25.03.2018 - trânsito em julgado em 05.07.2019 - processo de execução iniciado em 28.08.2018 - fls. 186/187). Conforme a jurisprudência, o legislador não estabeleceu os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados, entendendo-se que a fração mínima de 1/6 deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, mas quando há situações específicas, como é o caso, reincidência específica, é permitido o aumento superior a 1/6. Neste sentido: Apelação Criminal 0000011-85.2014.8.26.0536. Assim, exaspero a pena nesta fase em 1/5 (um quinto) e fixo a pena intermediária em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 720 dias-multa.

Em relação ao crime de falsa identidade, diante da reincidência (não específica), agravo a pena intermediária em 1/6 (um sexto), fixando-a em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para o crime do art. 307 do Código Penal.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição, destacando-se que o réu é reincidente específico (autos nº 0000234-19.2018.8.26.0691 - data do fato em 25.03.2018 - trânsito em julgado em 05.07.2019 - processo de execução iniciado em 28.08.2018 - fls. 42-43), razão pela qual não faz jus a minorante do parágrafo 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Os crimes foram praticados em contextos distintos, assim, aplicável a regra do artigo 69, do Código Penal, devendo as penas serem unificadas, resultando na pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 720

dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, e na pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para o crime de falsa identidade, executando-se primeiro aquela.

Considerando o quantum da pena fixada e a reincidência específica do réu quanto ao tráfico de drogas, o regime inicial a ser fixado deve ser o fechado. Em relação ao crime de falsa identidade, punível com detenção, o regime inicial deve ser o semiaberto, considerando a reincidência.

Diante da quantidade da pena e da reincidência, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão de sursis (CP, arts. 44 e 77).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para o fim de CONDENAR o réu JOÃO VITOR DE SOUSA pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 720 dias-multa no valor individual de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e pela prática do crime tipificado no art. 307 do Código Penal à pena de 03 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, executando-se primeiro a pena de reclusão nos termos do artigo 69, do Código Penal.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. CONDENO o sentenciado ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804), observando-se a gratuidade que ora lhe concedo.

4.2. Não permito que o réu recorra em liberdade. Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, diante da subsistência dos motivos já expostos nas decisões anteriores e por entender presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada. Com efeito, o fumus comissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria do crime atribuído ao réu. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do crime praticado pelo réu, da possibilidade concreta de o réu voltar a delinquir, considerando que é reincidente específico pelo crime de tráfico de drogas e já foi responsabilizado quando menor também por tráfico, ficando internado na Fundação Casa,, a demonstrar que faz do comércio de drogas seu meio de vida, bem como da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não existem garantias de que em liberdade não se afastará do distrito da culpa. Vale ressaltar, sobre outro aspecto, que "A prisão preventiva pode ser mantida por ocasião da sentença condenatória recorrível que aplicou o regime semiaberto para o cumprimento da pena, desde que persistam os motivos que inicialmente a justificaram e que seu cumprimento se adeque ao modo de execução intermediário aplicado. De fato, não é razoável manter o réu constricto preventivamente durante o desenrolar da ação penal e, por fim, libertá-lo apenas porque foi agraciado com regime de execução diverso do fechado, permitindo-lhe que, solto, ou mediante algumas condições, aguarde o trânsito em julgado da condenação. Sufragar tal entendimento vai contra ao já sedimentado tanto no STF quanto no STJ, no sentido de que, quando presentes as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, "Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade" (STF, HC 89.089-SP, Primeira Turma, DJ de 1º/6/2007). Por outro lado, tendo em vista a imposição do regime semiaberto na condenação, se faz necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o aludido modo de execução, sob pena de estar-se impondo ao condenado modo mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade. Precedentes citados: RHC 39.060-RJ, Quinta Turma, DJe 10/3/2014; e HC 244.275-SP, Sexta Turma, DJe 18/3/2013". (RHC 53.828-ES, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 14/4/2015, DJe 24/4/2015). Isto posto, EXPEÇA-SE guia de execução provisória. Além disso, ANOTE-SE a revisão da prisão no sistema SAJ, notadamente para futura reapreciação, devendo a Serventia observar o disposto no COMUNICADO CG nº 78/20201.

4.3. Considerando a demonstração de que o dinheiro apreendido é produto do crime de tráfico de drogas, e diante da ausência de prova da origem lícita do aparelho celular, com fundamento no art. 91, II, "b", do Código Penal c/c art. 63, I, da Lei 11.343/06, como efeito secundário da condenação, DECRETO o perdimento em favor da União do valor e aparelho celular apreendidos (fls. 13/14). Com o trânsito em julgado da presente sentença, PROCEDA-SE a reversão da quantia em favor do FUNAD e o necessário em relação ao celular.

4.4. DEIXO DE ARBITRAR o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresso acerca do montante a ser ressarcido, bem como, por consequência, da ausência de contraditório acerca da matéria.

4.5. COMUNIQUE-SE a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ), e com o trânsito em julgado intime-se o réu para pagamento das custas judiciais (art. 479, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE Certidão de Sentença, extraída na forma do artigo 164 da Lei nº 7.210/84 e artigos 479-B e 480-A das NSCGJ. Expedida a Certidão, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público, para que, querendo, proponha a competente ação de execução da pena de multa na Vara das Execuções Criminais. Após, deverá a z. Serventia lançar a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal". I. Comunicado pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, deverá a z. Serventia proceder à anotação no histórico de partes do evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e lançando a movimentação "Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", arquivando-se a seguir. II. Não havendo comunicação pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, aguarde-se o transcurso do lapso prescricional. Após, volvam-me os autos cls. para declaração da extinção da pena.

4.6. DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (art. 72, da Lei nº. 11.343/2006), caso a providência já não tenha sido adotada.

4.7. Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ).

4.8. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Buri, 07 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA